

第1問

妻Xと夫Yは、長男Aが生まれて間もなく離婚し、Xが親権者として1人でAを育てることになった。親権を失ったYは、一人暮らしをしていた。やがてXは育児に疲れ、YにAを育ててもらおうと思い、Yの帰宅時間前に道路からは見えないY宅の勝手口付近に生後3か月のAを無断で置いて立ち去った。Yは、帰宅してすぐにAに気付いたが、子どもの面倒を見るのが煩わしかったので、Aが死亡してもかまわないと思いながらそのまま放置した。翌日、Aが家の外に寝かされているのを隣家の2階から偶然見かけて不審に思った隣人の甲がY宅を訪れたが、Yが不在だったため、甲は勝手口付近でぐったりしていたAを病院に運び、これによりAは一命を取り留めた。

X及びYの罪責を論ぜよ。

(同志社大学法科大学院 平成17年度)

第1 Xの罪責

保護責任者遺棄罪（218前段）の成否が問題となる（問題文の事情だけでは、Xには殺意までは認められない。）。

親権者であるXに保護責任が認められることは明らかだろう。また、「遺棄」（218前段）に作為形態（≡移置）が含まれることには争いがない。

やや問題となるのは、Y宅にAを置いている点だが（一切危険性が発生しない場合には、本罪を準抽象的危险犯として捉える見解（抽象的危险犯でもおよそ危険性が発生しない場合には、処罰しないとする考え方）からは、本罪の成立が否定され得る。）、かかる行為に出たのがYの帰宅時間前であることからすると、少なからず危険性の発生があるといえる。

第2 Yの罪責

不作為による殺人罪（199）の成否が問題となる（**論点** 不真正不作為犯～実行行為性 ■ 司H22,H26,H30,旧H8-1,H16-1,H22-1）。

総合 16 頁 論証 1 頁

既にXとは離婚しており、Yは親権を失っているから、法令によって作為義務を基礎付けることは難しい。残るは排他的支配の設定（排他的支配領域性）だが、自己の意思によらないそれが作為義務を基礎付けるのかについては、学説上争いがある。

作為義務を認めた場合には、実行の着手時期（43本文）も問題となる。

不作為犯における実行の着手は、作為義務違反の不作為が始まっただけでは足りず、結果発生の危険性が一定程度に高まった時点において認められると解されているところ、Aの年齢を考えれば、Xによって放置された時点で生命侵害の危険性が一定程度に高まったといえる。もっとも、YがAが放置されていることを認識したのは、その後であるから、その時点にならなければ故意が認められない。

したがって、その時点で実行の着手が認められることになるだろう。

答案構成

第1 Yの罪責

1 殺人未遂罪（203、199）の成否

↓

2 不真正不作為犯の肯否

↓

肯定説

↓

①作為義務、②作為の可能性・容易性

↓

あてはめ

↓

3 実行の着手時期

↓

4 故意

↓

5 Yには殺人未遂罪が成立する

第2 Xの罪責

1 保護責任者遺棄罪（218前段）

↓

2 要件検討

↓

3 Xには保護責任者遺棄罪が成立する

第3 XとYの共犯の成否

意思連絡がなく、共同正犯（60）は成立しない

第1 Yの罪責

1 Yは、Y宅の勝手口付近に生後3か月のAがいることに気付いたが、
 2 子どもの面倒を見るのが煩わしかったので、Aが死亡してもかまわない
 3 と思いながらそのまま放置している。かかる不作为について、殺人未遂
 4 罪（203条、199条）の成立が考えられる。

5 2(1) まず、「殺した」という作為の形で規定された犯罪について、不作
 6 為による実行行為性が認められるか。

7 (2) 実行行為は犯罪の結果発生の実害的危険を有する行為である。そう
 8 だとすれば、このような結果発生を危険を不作为によって実現するこ
 9 とは可能である。

10 したがって、不作为による行為にも実行行為性を認めることはでき
 11 る。

12 しかし、不真正不作为犯の成立要件は法律上明示されていない。に
 13 もかかわらず、これを限定しなければ明確性の原則に反する結果とな
 14 り、処罰範囲が拡大し、刑法の自由保障機能を害する。

15 そこで、不真正不作为犯の成立を限定する必要がある。具体的
 16 は、不作为に、作為によって当該構成要件を発生することとの同価値
 17 性が認められることが必要であると解する。

18 まず、①行為者に作為義務が認められることが必要である。かかる
 19 作為義務の有無は、法令・契約・事務管理・先行行為（危険創出行
 20 為）・危険の引受け・排他的支配・社会継続的保護関係等の事情を総
 21 合して判断すべきである。②また、法は不可能を強いるものではない
 22

1

1 から、作為の可能性・容易性も必要であると解すべきである。

2 (3) 本件では、Yに既に親権はなく、法令上の監護義務は認められない
 3 （民法818条1項、820条）。

4 しかし、Aが放置されていたのは、道路から見えず、他人が容易に
 5 入ることのできないY宅の勝手口付近である。

6 したがって、Yは、因果経過を具体的・現実的に支配していたとい
 7 え、排他的支配の設定が認められる。

8 確かに、Aを放置したのはXであるが、他人によるものとはいえ、
 9 生後3か月であるAを保護できる状況にあるのはYのみだったのであ
 10 る。そして、Yにとっては、病院へ運ぶなど、Aに必要な保護を与え
 11 ることは容易だったと考えられる。このような作為の容易性も併せ考
 12 えると、排他的支配の設定が自己の意思によるものでなくとも、作為
 13 義務を認めるのが相当である。

14 したがって、①YにはAに必要な保護を与えるという作為義務が認
 15 められる。

16 (4) そして、②Yにとって、Aに必要な保護を与えるという作為をなす
 17 ことは、可能であり、かつ上記のように容易であるといえる。

18 したがって、Yの上記放置には実行行為性が認められる。

19 3 不作为犯における実行の着手（43条本文）は、作為義務違反の不作
 20 為が始まっただけでは足りず、結果発生危険性が一定程度に高まった
 21 時点において認められるところ、上記のようなAの年齢を考えれば、A
 22 は放置されただけで、生命侵害の危険性が一定程度に高まったといえ

2

る。

もっとも、YがAの存在を認識するまでは故意（38条1項）が認められないから、結局その時点で、実行の着手が認められる。

4 Yは、Aが死亡してもかまわないと思っており、殺意が認められる。

5 以上より、Yには殺人未遂罪が成立する。

第2 Xの罪責

1 XがY宅の勝手口付近に生後3か月のAを無断で置いて立ち去った行為について、保護責任者遺棄罪（218条前段）の成立が考えられる。

2 Aは上記のように生後3か月であり、「幼年者」であって「扶助を必要とする者」（217条参照）に当たる。

また、Xは、Aの親権者であり、法令上子であるAに対する監護義務を負う。したがって、Xは「幼年者……を保護する責任のある者」に当たる。

次に、XはAをY宅前に放置しているが、218条前段の「遺棄」に作為形態である移置が含まれることは争いがないから、「遺棄」といえる。

また、Xにはその旨の認識も認められるから、故意に欠けるところもない。

3 したがって、Xには保護責任者遺棄罪が成立する。

第3 XとYの共犯の成否

以上より、Xには保護責任者遺棄罪、Yには殺人未遂罪が成立する

が、XY間には意思連絡がないので「共同して犯罪を実行した」とはいえず、共犯関係（60条）は成立しない。

したがって、それぞれ単独犯が成立する。

以 上